

1046668-71.2021.8.26.0100

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Franquia

Magistrado: Andre Salomon Tudisco

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Cível

Vara: 1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM

Data de Disponibilização: 22/08/2022

... comportamentos oportunistas prejudiciais ao tráfico. O princípio do "pacta sunt servanda" mostra-se necessário ao giro mercantil na medida em que freia o natural oportunismo dos agentes econômicos" (op. cit. ).

De igual forma, não subsistem argumentos sobre a anulação do contrato de franquia.

Não foi alegada qualquer causa de sua anulação. Os requerente alegam, em verdade, fatos que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Cível

1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM

Praca Doutor Joao Mendes, S/N, São Paulo - SP - cep 01501-000

1046668-71.2021.8.26.0100 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1046668-71.2021.8.26.0100

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Franquia

Requerente e Reconvinte:

Fca Serviços Automotivos Ltda e outro

Requerido e Reconvindo:

Ss Franchising e Comercio de Produtos Automotivos Eireli e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Andre Salomon Tudisco

Vistos.

Trata-se de ação ajuizada por FCA Serviços Automotivos LTDA contra SS Franchising e Comércio de Produtos Automotivos Eireli. Aduz, em síntese, que firmou com a ré contrato de franquia e que, na constância da execução do contrato, a requerida, franqueadora, teria descumprido as cláusulas contratuais, bem como a Lei de Franquias. Alega que a requerida não apresentou documentos obrigatórios quando da assinatura do Contrato, subdimensionou os custos do investimento inicial, omitiu a relação completa de franqueados, não possui registrada a marca da franquia, prestou informações inverídicas no momento da contratação, assim como afirma que houve ausência de assistência à operação da unidade, imposição de custos não pactuados para marketing da unidade e exigência de obrigações abusivas e não previstas no contrato. Requer a confirmação da tutela de urgência e que seja declarada a nulidade do Contrato de Franquia ou, alternativamente, a rescisão por culpa exclusiva da requerida, assim como declarar a inaplicabilidade da cláusula 17.4 do contrato (cláusula de não concorrência).

Indeferida a tutela de urgência (fls. 214/218).

A requerida apresentou contestação com reconvenção (fls. 375/422) alegando, preliminarmente, a irregularidade da representação da autora. No mérito, alega que inexistem nulidades contratuais ou descumprimentos contratuais de sua parte. Alega

a aplicação da lei nº 8.955/94, em razão da data da pactuação. Sustenta a regularidade de suas marcas, inclusive registradas perante o INPI. Por fim, alega a validade do contrato e da cláusula de não-concorrência. Em reconvenção, requer a rescisão contratual por culpa exclusiva da reconvinda, subsidiariamente requer a rescisão antecipada do contrato, condenando-a em multa por rescisão antecipada. Requer, ainda, a condenação da reconvinda ao pagamento de R\$ 116.000,00 relativo às multas contratuais de royalties em atraso.

Emenda à petição inicial de reconvenção (fls. 519/521).

Deferida a tutela de urgência para o reestabelecimento do site da autora e intimando a reconvinda a apresentação de contestação à reconvenção (Fls. 691/692)

A reconvinda/autora apresentou contestação à reconvenção e réplica (Fls. 703/743), alegando o afastamento da preliminar de ausência de representação processual. No mérito, alega que a ré vem dificultando as atividades da autora, razão pela qual não teria conseguido realizar o pagamento dos royalties devidos. No mais, afirma que em 19.05.21 realizou o pagamento de todos os royalties em aberto, razão pela qual não são aplicáveis as penalidades postuladas pela reconvinte.

Alternativamente, requer sejam as multas aplicadas em consonância à cláusula 21.8 do contrato e equitativamente reduzidas em consonância com o art. 413 do Código Civil.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo antecipadamente a demanda.

É o caso de parcial procedência dos pedidos autorais e procedentes os reconventionais.

Por determinação do art. 2º da Lei nº 8.955/94, "Franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício".

Ademais, acerca das obrigações essenciais vinculadas ao contrato de franquia, ensina Carlos D. A. Braga que "considerando os elementos essenciais do conceito de franquia empresarial (...) podemos identificar algumas obrigações características", sendo que "[a]s obrigações do franqueado consistem basicamente no seguinte: (i) realizar o pagamento da contraprestação devida em razão da licença de uso de marca e da prestação de serviços de assessoria técnica empresarial, normalmente dividida em uma taxa inicial (também chamada de taxa de franquia) e em pagamentos mensais calculados com base em um percentual sobre o faturamento do franqueado (royalties); (ii) oferecer aos consumidores apenas produtos ou serviços sob a marca licenciada pelo franqueador, por ele fabricados ou por quem ele indicar; (iii) observar estritamente as instruções de comercialização dos produtos e serviços estabelecidas pelo franqueador" e que "[a]s obrigações do franqueador, por sua vez, são: (i) conceder ao franqueado o direito de uso de sua marca; (ii) prestar os serviços de assessoria técnica de organização empresarial" (in Tratado de Direito Comercial, volume 6: estabelecimento empresarial, propriedade industrial e direito da concorrência. Fábio Ulhoa Coelho (coord.). São Paulo: Saraiva, 2015. pp. 181). Foram apontadas na inicial, como descrito no relatório, as seguintes condutas supostamente irregulares da requerida:

I - não apresentou documentos obrigatórios quando da assinatura do Contrato;

II - subdimensionou os custos do investimento inicial;

III - omitiu a relação completa de franqueados;

IV - não possui registrada a marca da franquia;

V - prestou informações inverídicas no momento da contratação;

VI - ausência de assistência à operação da unidade;

VII - imposição de custos não pactuados para marketing da unidade e

VIII - exigência de obrigações abusivas e não previstas no contrato

As alegações de que a requerida não apresentou documentos, subdimensionou os custos

do investimento inicial, omitiu a relação completa de franqueados e que prestou informações inverídicas no momento da contratação encontram óbice, primeiramente, na tempestividade dos argumentos.

A autora firmou com a ré o contrato de franquia (fls. 83/109) em 21 de setembro de 2017, ou seja, aproximadamente quatro anos antes do ajuizamento da presente ação. Nesse tempo, a autora operou regularmente a franquia, como opera até o momento. Não é possível dizer, portanto, que os supostos descumprimentos do contrato pela ré teriam inviabilizado ou dificultado o negócio.

Não se observa, ademais, que o alegado subdimensionamento dos custos da franquia teria sido sequer substancial, posto que foi apenas de 20% e não se sabe sobre a negociação dos preços dos bens e serviços utilizados.

Ademais, as supostas nulidades por falta de apresentação de informações ou mesmo as de que a requerida teria omitido ou inventado fatos e números não foram aduzidas tempestivamente e, portanto, não podem ser vistas como a razão para o pedido de encerramento do contrato.

Quanto à alegação de que a requerida não possui a marca da franquia, esta também não procede.

A autora aponta que a COF indica que a requerida possui a marca LAAV, registrada perante o INPI sob o nº 910422281. Todavia, sustenta que tal marca não se refere aos serviços prestados e que posteriormente a requerida teria alterado sua identidade de marca e, portanto, tal registro seria ineficaz para proteger as marcas da franquia.

Todavia, a requerida colaciona o registro de marca mista (fls. 443/445) que coincide com a utilizada pelas franquias.

O ocorrido, troca da identidade marcária da franquia, não encontra óbice em nenhuma cláusula contratual. No mais, não há alegações de que a marca da franquia teria afetado o sucesso do negócio da autora, razão pela qual não poderia ser reconhecido como razão para nulidade contratual ou mesmo descumprimento de alguma cláusula.

Quanto às alegações de ausência de assistência, imposição de custos não pactuados para marketing e exigência de obrigações não previstas em contrato, estas também não procedem.

A alegação de ausência de assistência se refere ao dia da inauguração da loja e ausência de transferência de know how no decorrer do contrato.

Quanto à ausência de assistência na data da inauguração, pelos mesmos motivos narrados anteriormente, não há como acolhe-la. Este fato ocorreu há quase quatro anos e não é capaz, por si só, de gerar a completa ineficácia do negócio.

Quanto à ausência de transferência de know how no decorrer do contrato, esta também não procede. A autora não alega uma sucessão de momentos em que tenha solicitado assistência à ré e esta tenha lhe sido negada. Os pontos que trouxe dizem respeito à relação natural entre franquia e franqueador, bem como relação natural entre os franqueados, que auxiliam uns aos outros.

Ademais, a alegação de que teria fornecido manuais elaborados por si mesma à requerida, esta não importa, diretamente, na comprovação de que a requerida não possuía know how e não teria o repassado à autora.

Quanto à suposta imposição de custos não pactuados para marketing, a alegação também não procede.

A autora alega que o contrato de franquia prevê sua isenção aos custos de marketing, porém que a requerida exige que a autora e as demais franqueadas mantenham site próprio e que efetuem publicidade segundo suas exigências.

Como se observa, de fato não há interferência da franqueadora na gestão de marketing da autora. No mais, vê-se que em mensagens entre as partes, a autora teria solicitado orientação à ré sobre o tema, então ensejando os gastos relatados (fls. 493/496).

Em suma, não há comprovação nos autos de que a ré tenha imposto o gasto de valores ou a cobrança de algo quanto ao marketing.

Em verdade, a relação de franquia tida entre as partes perdurou por longos e anos e se sustenta até o momento. Eventual insucesso da requerente, ainda que pontual, não

pode ser apontado à requerida, tendo em vista não ter sido verificada a procedência e quaisquer das alegações.

Portanto, há que se reconhecer a improcedência do pedido de rescisão do contrato de franquia por justa causa da franqueadora, bem como o pedido alternativo de anulação do contrato, visto que as alegações que os fundamentam não encontram lastro no conjunto probatório acostado aos autos.

Assim, em que pese as alegações e documentos trazidos pelos autores, estes, por si só, não são suficientes para evidenciar a justa causa para rescisão do contrato por culpa da franqueadora tampouco a nulidade do contrato de franquia que, diga-se, vigorou por anos.

Superada tal análise, em que pese a inexistência de qualquer irregularidade na conduta da franqueadora que dê causa à rescisão contratual por sua culpa, observo a nulidade da cláusula de não concorrência prevista na cláusula 17.4 do contrato de franquia (fl. 101), que prevê:

"17.4 O FRANQUEADO, seus sócios ou parentes não poderão, durante o prazo de vigência deste contrato e após o seu término, por um período de 5 (cinco) anos, direta ou indiretamente, operar o SISTEMA, em outros locais que não a UNIDADE ou outra unidade franqueada, participar de outras empresas ou colaborar direta ou indiretamente com empreendimentos que atuem em segmentos de mercado concorrentes, conflitantes ou afins ao SISTEMA.".

Assim, a validade da cláusula de não concorrência inserida no contrato empresarial depende da observação de dois requisitos: os limites temporal e espacial.

Como ensina Fábio Ulhoa Coelho:

As cláusulas contratuais de disciplina da concorrência podem ou não ser válidas, de acordo com uma série de fatores, a serem especificamente analisados. Para a análise, o critério mais relevante é o da preservação do livre mercado. Ou seja, as partes podem disciplinar o exercício da concorrência entre elas, desde que não a eliminem por completo. Em outros termos, a validade da disciplina contratual da concorrência depende da preservação de margem para a competição (ainda que futura) entre os contratantes; ou seja, da definição de limites materiais, temporais e espaciais. Em concreto, a vedação não pode dizer respeito a todas as atividades econômicas, nem deixar de possuir delimitações no tempo ou no espaço. Em relação aos limites materiais, observa-se que a cláusula disciplinando a concorrência é inválida, se impede o contratante de explorar qualquer atividade econômica. A restrição deve necessariamente se circunscrever a determinados ramos de comércio, indústria ou serviços. Para as demais atividades, as partes ficam livres de qualquer obrigação (de não fazer). A propósito da restrição material, deve-se também considerar inválida a cláusula que impeça o contratante, pessoa física, de exercer a sua profissão. Por exemplo, o sócio que se desliga de sociedade de engenheiros pode, no instrumento de cessão de cotas, ficar impedido de competir com a sociedade, desde que os termos contratados não alcancem todas as atividades de engenharia para as quais o retirante se encontra profissionalmente habilitado ou preparado. Também é inválida a cláusula que vede a concorrência para sempre ou em qualquer lugar. Limites temporais ou espaciais são exigidos, para que a restrição contratada não importe eliminação total da concorrência. Trata-se, aqui, de uma alternativa inclusiva; quer dizer, o contrato pode prever limite no tempo e no espaço, ou só num deles. A restrição contratual limitada apenas geograficamente se considera feita para sempre, enquanto a limitada apenas no tempo alcança todos os mercados (Ripert-Roblot, 1947:350). A invalidade existe quando não há simultaneamente limite temporal e espacial. É igualmente inválida a cláusula de não concorrência que estabelece prazo demasiado longo, ou defina limites espaciais exagerados, que ultrapassem o potencial de conquista de mercado que as partes possuem. Desse modo, é nula a cláusula de não estabelecimento que o empreendedor de shopping center, para evitar a concorrência autofágica, contrata com os lojistas, quando os limites territoriais nela referidos extrapolam os do mercado sobre o qual pode exercer atração (in Curso de Direito Comercial, v. 1, cap. 7, São Paulo, RT, 2018 - grifado).

Este é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, na oportunidade do julgamento do REsp 1.203.109/MG, relatado pelo Ministro Marco Aurélio Bellizze,

decidiu que: "São válidas as cláusulas contratuais de não-concorrência, desde que limitadas espacial e temporalmente, porquanto adequadas à proteção da concorrência e dos efeitos danosos decorrentes de potencial desvio de clientela - valores jurídicos reconhecidos constitucionalmente".

No presente caso, embora presente o requisito temporal, de 5 anos após o término da relação contratual, não foi estabelecido qualquer limite espacial, de modo que não se revela razoável impor à autora tal limitação.

Assim, resta configurada a procedência da demanda quanto à nulidade e consequente inexigibilidade da cláusula contratual de não concorrência.

Em pedido reconvenicional, a reconvinte aponta o atraso do pagamento de royalties e ausência de envio de relatórios dos meses de abril, maio e junho de 2021 e aplicação de multa por rescisão antecipada, totalizando débito no valor de R\$ 83.000,00 (fl. 520).

A reconvinda alega que realizou os pagamentos dos royalties em abril e maio de 2021 mediante o depósito judicial de fls. 632/662, em 19.05.2021, ou seja, após o vencimento que se dá todo dia 05 de cada mês (cláusula 9.2 - fls. 92).

Ainda, prevê a cláusula 21.2 (fls. 106) a aplicação de multas com base em salários mínimos conforme ocorrerem descumprimentos contratuais, dentre esses o atraso no pagamento dos royalties e a apresentação dos relatórios de faturamento.

Por fim, havendo sucessivos atrasos de pagamento de royalties, a reconvinda incide em hipótese de rescisão contratual por sua culpa, por infração à cláusula 9.2 (pagamento tempestivo de royalties), nos termos da cláusula 19.2 (fls. 103).

Vê-se que a reconvinda não se desincumbiu de seu ônus de provar causa impeditiva ou modificativa do direito da reconvinte, que possui direito na cobrança da referidas multas por atraso e, em decorrência dos ditos atrasos, também possui direito em requerer a rescisão contratual por justa causa da reconvinda.

A propósito, observa-se que o contrato pactuado entre as partes tem natureza empresarial. E, como ensina Paula Forgioni, o funcionamento do mercado exige que os pactos sejam respeitados, de forma que "A força obrigatória dos contratos viabiliza a existência do mercado, coibindo o oportunismo indesejável das empresas" (in Contratos Empresariais. Teoria e Aplicação, 3ª ed., pp. 109/112, São Paulo, RT, 2018).

Ainda sobre o pacta sunt servanda, a Professora aponta que "Se lhes fosse permitido, os agentes econômicos valer-se-iam dos contratos para vincular apenas seus parceiros comerciais, e nunca a si próprios. No momento inicial, as partes creem que o negócio ser-lhes-á vantajoso; todavia, com o passar do tempo, é possível que o vínculo deixe de interessar a uma delas. Nasce anseio de se livrar da amarra contratual para seguir outro caminho. Partindo dessa premissa, compreende-se a importância sistêmica da força vinculante dos contratos; na sua ausência, seria impossível a coibição do descumprimento da palavra empenhada e o desestímulo de comportamentos oportunistas prejudiciais ao tráfico. O princípio do "pacta sunt servanda" mostra-se necessário ao giro mercantil na medida em que freia o natural oportunismo dos agentes econômicos" (op. cit. ).

De igual forma, não subsistem argumentos sobre a anulação do contrato de franquia. Não foi alegada qualquer causa de sua anulação. Os requerente alegam, em verdade, fatos que ocorreram na constância do contrato, não havendo qualquer indicação de dolo, fraude, coação ou qualquer outra razão que ensejasse a anulação do contrato. Outrossim, subsistindo a rescisão por justa causa da autora/reconvinda, há que ser julgada improcedente a demanda da franqueada quanto aos seus demais pedidos.

Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para reconhecer a nulidade da cláusula 17.4 (não competição) do contrato e PROCEDENTES OS RECONVENCIONAIS, declarando rescindido o contrato por justa causa da reconvinda/autora, bem como condenando-a ao pagamento da multa por rescisão antecipada e multas por atrasos de pagamentos dos meses de abril, maio e junho de 2021. Condeno, ainda, a reconvinda/autora a proceder à descaracterização de sua unidade franqueada, consoante os termos rescisórios do contrato.

Em relação ao processo principal, levando-se em conta a sucumbência mínima da ré-reconvinte, arcará a autora-reconvinda com a integralidade das custas, despesas processuais e honorários, que fixo em 10% sobre o valor da causa.

Sobre a reconvenção, condeno a autora nas custas e despesas processuais, bem como honorários dos patronos do réu, os quais fixo em 10% do valor da causa atualizado somado à 10% do valor de sua condenação, também atualizada.

P.R.I.C

São Paulo, 12 de abril de 2022.